论被执行主体之扩张

谭兆强

一、问题的提出

“被执行人难找,被执行财产难寻,协助执行人难求,应执行财产难动”是中共中央1999年第11号文件转发的《中共最高人民法院党组关于解决人民法院“执行难”问题的报告》明确提及的执行工作“四难”。为破解执行难题,学界和司法实务界提出并采取了各种解决办法:如建立公安协助查扣被执行人制度、建立财产申报制度,加大法院调查财产力度,建立审计调查制度;[1]司法实践中,创造出被执行人申报财产、人民群众举报财产、债务人名录公示、限制债务人高消费等方式方法。[2]诚然,在党中央直接重视,[3]全社会共同关心,人民法院艰苦卓绝地努力下,历时数年,执行工作中的“四难”已在很大程度上得到缓解,但“执行难”问题尚未得到根本扭转,[4]迄今仍然困扰着人民法院的执行实践。[5]根据中央1999年第11号文件,执行难的首要原因是被执行人难找、被执行财产难寻。查找被执行人和被执行财产首先以确定被执行人为前提,否则就会成为无矢之的。司法实践中,执行法院通常依执行依据的记载直接确定被执行人即被执行主体,但被执行主体存在依据法律、司法解释扩张确定的情形。学界对被执行主体扩张问题缺乏系统研究,无法为被执行主体扩张提供理论支撑。因此,有必要对此问题进行深入研究,以促进执行理论的发展,统一司法适用,扩大可供执行财产的范围,增强履行义务能力,缓解“执行难”问题。

通说认为,被执行人指依执行依据,负有容忍执行机构实施司法强制力而为给付义务的人。[6]笔者认为,被执行人内涵应有广、狭义之分。上述表述是狭义的被执行人内涵。广义的被执行人,包括狭义的被执行人和扩张确定的被执行主体,即依执行依据直接确定或者依法律、司法解释导致执行依据效力扩张而确定的,负有容忍执行机构实施司法强制力而为给付义务的人。“执行当事人,原则上应依执行名义之记载定之。于执行名义成立后,继受执行名义所载当事人之地位者,亦得为执行债权人或执行债务人。”[7]由此可知,执行法院原则上依执行依据的记载直接确定被执行主体,在执行依据生效后,依法律、司法解释继受执行依据所载被执行人之地位者,执行法院可扩张确定,即被执行主体之扩张。本文从广义的被执行人之角度探讨被执行主体之扩张问题。

二、被执行主体扩张的理论依据

笔者认为,被执行主体扩张的理论依据是既判力主观范围扩张理论。现代民事诉讼制度,出于法的安定性和程序保障的价值,赋予判决终局性效力。判决的终局性体现于其所具有的形式上的确定力、实质上的确定力等一系列的效力之中。[8]判决在形式上的确定力,就是说判决是确定的、终局的。实质上的确定力即既判力,表现为当

〔1〕参见李浩:“论民事执行中债务人财产的发现”,载《法学》2007年第12期。

〔2〕邢君:“为执行难立法建制”,载《法制日报》2004年7月27日第11版。

〔3〕针对“执行难”问题,党中央专门下发了〔1999〕11号文件部署解决;中纪委、中央政法委等国家机关下发了中纪发〔1999〕17号、中纪发〔2006〕16号、政法〔2005〕52号等文件支持解决。2002年党的16大报告明确提出“切实解决执行难问题”。

〔4〕2006年10月30日,时任最高人民法院院长肖扬在向10届全国人大常委会第24次会议作关于开展规范司法行为专项整改报告时仍然坦承:人民群众反映强烈的“执行难”问题尚未得到根本扭转。

〔5〕2009年3月10日,最高人民法院院长王胜俊在向第11届全国人民代表大会第2次会议上作最高人民法院工作报告时提出:执行难等问题还需要花大气力予以解决。

〔6〕江伟主编:《民事诉讼法学原理》,中国人民大学出版社1999年版,第809页。

〔7〕杨与龄编:《强制执行法论》,中国政法大学出版社2002年版,第38页。

〔8〕江伟主编:《民事诉讼法学专论》,中国人民大学出版社2005年版,第77页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

事人在判决决定后，不能就判决决定的法律关系另行起诉，也不得在其他诉讼中就同一法律关系提出与本案诉讼相矛盾的主张。[9] 既判力的范围包括主观范围和客观范围两个方面：主观范围是指既判力及于什么人，对什么人发生作用；客观范围是指既判力及于什么事，对什么事发生作用。既判力功能在于定分止争，解决民事纠纷，既判力的主观范围原则上只能在对立的诉讼当事人之间产生，只有这样才符合程序保障的要求，符合民事诉讼的辩论原则和处分权原则，但在一定条件下可以扩张，即既判力主观范围的扩张。如果限制既判力扩张至一般第三人，民事诉讼法所追求的纠纷的合理、高效解决的目标将难以实现。既判力主观范围扩张的根据可从两个侧面分析。首先，作为被继受的当事人在前诉进行中已经获得了充分的程序保障，并由此被既判力所拘束；而继受人在继受实体利益的同时，也将受既判力拘束的利益加以继受。其次，从与胜诉当事人的关系看，既判力当然有利于胜诉当事人的继受人。而其相对人的败诉当事人在得到程序保障的前提下没有取得争执的标的，说明其败诉失去利益欠缺实体法和程序法的保护，因此应该接受该不利后果。再从与败诉当事人的继受人的关系来说，继受人在败诉当事人败诉的前提下继受败诉当事人在前诉获得的不利判决，该判决又是合法判决时，对他来说也无不当之处。[10] 既判力向第三人扩张，其实扩张的正当根据在前诉中已经形成。

从域外立法来看，大陆法系国家大多对既判力向第三人的扩张作了规定。例如，《德国民事诉讼法》第325条第1款规定："确定判决的效力，利与不利，及于当事人、在诉讼系属发生后当事人的承继人以及作为当事人或其承继人的间接占有人而占有系争物的人。"《日本民事诉讼法》第201条第1款规定："确定判决对当事人、口头辩论终结后的继承人或为了当事人和其承继人的利益而占有请求标的物的人，有其效力。"

当然，允许既判力向一般第三人扩张，为防止侵害民事诉讼固有的程序保障的理念，应该采取相应的程序来保障既判力扩张的正当性。既判力主观范围的扩张，在执行阶段表现为执行力主观范围的扩张即执行当事人之扩张，包括申请执行人之扩张和被执行主体之扩张。执行法院应严格依法律、司法解释规定的程序审查确定执行力主观范围的扩张，而不能由法官依自由裁量权而任意扩张，以保障执行力主观范围扩张的正当性。从理论上说，作为执行依据的法院裁定书、调解书、公证债权文书、仲裁裁决、行政非诉法律文书，其效力与确定的终局判决的执行力相同；在对人的效力所及的范围上，也与对判决的执行一样，可以扩张确定被执行人。

三、被执行主体扩张的情形

根据现行法律和司法解释规定，被执行主体之扩张包括变更、追加之被执行人、被执行人到期债权之第三人、执行担保人、履行责任人等情形。有学者指出，执行到期债权的第三人、执行担保人等情形属于变更、追加被执行义务主体范畴。[11]笔者对此不赞同，因为三者之间在适用的理论依据、程序和具体法律规定上都有所不同，现详述之。

（一）变更、追加之被执行人

根据既判力主观范围扩张理论，判决对于人的效力，原则上只能及于其上明确记载的债权人与债务人。但是，当法律文书生效并开始执行后，其上载明的债权人和债务人可能因为某种原因而不存在，如公民死亡、法人或者其他组织终止，这就需要考虑变换执行当事人，也就是说要变更或追加执行当事人。学理上称之为执行承担。[12]变更或追加执行当事人包括申请执行人之变更和被执行之人变更、追加。被执行之人变更是指执行依据上载明的被执行人已经不存在（如公民死亡或法人注销、合并等），而由其他公民、法人和其他组织代替原被执行人履行义务，执行依据只对变更后的被执行人有效。被执行之人追加是指执行依据上载明的被执行人不能履行或不能完全履行义务，而将与被执行人直接相关联的其他主体依法裁定增加为被执行人，与原义务人共同承担履行义务，执行依据对原被执行人和追加后的被执行人有效。

《民事诉讼法》第209条规定："作为被执行人的公民死亡的，以其遗产偿还债务。作为被执行人的法人或其他组织终止的，由其权利义务承受人履行义务。"该条确立了变更、追加被执行人制度。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第271条至274条、最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》（下称《执行规定》）第76条至第83条规定了变更、追加被执行人的各种情形。

〔9〕同注〔6〕，第282-283页。

〔10〕同注〔6〕，第299页。

〔11〕刘育林："变更与追加被执行人义务主体的类型和法律适用"，载《当代法学》2002年第7期。

〔12〕李浩主编：《强制执行法》，厦门大学出版社2004年版，第162页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

司法实践中,变更、追加被执行人须由法定的办理机构遵循严格的启动程序,并为当事人提供相应的救济程序。根据《民事诉讼法》第140条的规定,可以上诉的裁定只有三种:即不予受理裁定、对管辖权有异议的裁定、驳回起诉的裁定。因此,在现行法律框架下对变更、追加被执行人的裁定即使有异议也无权上诉。但如何保障被变更、追加被执行人的合法权益呢?笔者认为,应保障其执行异议权、复议权和申诉权。一是执行异议权、复议权。根据《民事诉讼法》第202条的规定,当事人、利害关系人(包括申请执行人、被执行人、被变更或追加的被执行人)对变更、追加被执行人的裁定有异议的,可以向执行法院提出书面异议。执行法院在法定期限内对此异议作出裁定。经合议庭审查发现确有错误,报本院审判委员会讨论决定后撤销原裁定;认为执行异议理由不成立的,应当裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的,可以向上一级法院申请复议。二是申诉权。根据《执行规定》第130条的规定,当事人、利害关系人对裁定不服,也可以向上级法院申请执行监督。

(二)被执行人到期债权之第三人

被执行人到期债权之第三人,是指被执行人不能清偿债务,但对第三人享有到期债权的,人民法院根据当事人的申请依法强制执行该第三人的财产。对被执行人到期债权之第三人的执行以债权人代位权为其实体法理论依据,略式诉讼程序理论和执行力扩张理论[13]是其程序法理论依据。[14]债权人代位权是指债务人怠于行使其对第三人享有的权利而危及债权人的权利时,债权人为保全自己的债权,以自己的名义行使属于债务人权利的权利。[15]债权人代位权实际上是债权人在特定情况下行使债务人的权利。略式诉讼程序是指针对特定的诉讼标的而采取简略诉讼方式,以迅速而简便地解决纠纷和实现权利义务关系稳定的诉讼程序。对第三人到期债权的执行是执行力扩张的具体表现。债权人依据执行依据申请对债务人的债务人为强制执行,实际上就是执行力扩张而及于该第三人,也即执行依据转作用于第三人,第三人因此必须履行。

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第300条规定:"被执行人不能清偿债务,但对第三人享有到期债权的,人民法院可依申请执行人的申请,通知该第三人向申请执行人履行债务,该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的,人民法院可以强制执行。"该条确立了对被执行人到期债权之第三人执行的制度。《执行规定》第61至第69条具体规定了对被执行人到期债权之第三人执行的程序、效力等内容。

司法实践中,执行被执行人到期债权之第三人须遵循执行当事人提出申请、执行法院向第三人发出履行通知、第三人异议及审查、对第三人强制执行程序。

(三)执行担保人

执行担保人,是指在强制执行中,被执行人要求暂缓执行,而向法院提供的担保人。执行程序非依法不得停止,但是,如果被执行人即时履行义务确有困难,并且为自己的履行提供充分的担保,以保证执行依据所载权利的实现,那么就可暂缓执行。

《民事诉讼法》第208条规定:"在执行中,被执行人向人民法院提供担保,并经申请执行人同意的,人民法院可以决定暂缓执行及暂缓执行的期限。被执行人逾期仍不履行的,人民法院有权执行被执行人的担保财产或者担保人的财产。"该条确立了执行担保制度。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第268至270条和《执行规定》第84条、第85条对执行担保的适用作了具体规定。

司法实践中,执行担保须遵循被执行人提出执行担保的申请、被执行人或其担保人提供充分、可靠的担保、申请执行人同意、执行法院准许程序。根据《民事诉讼法》第208条的规定,执行担保是向法院而非权利人提出。被执行人或其担保人以财产提供执行担保的,应当根据担保的性质和担保物的种类,将担保财产或权利凭证移交法院控制,或根据《物权法》的有关规定,到有关主管机关或者有关机构办理登记手续。

(四)履行责任人

履行责任人是指在执行程序中,源于被执行人的履行义务,负有实现执行依据确定内容的自然人。通常情况下,被执行人是以自己的名义履行义务并受执行法院的执行行为约束的人,但有时执行依据确定的被执行人并非执行程序中实际履行义务的人。如执行依据确定李四赔偿王五人民币10万元。李四是无民事行为能力人,有个人财产20万元,其监护人是张六。李四是被执行人,但由于其无民事行为能力,执行行为约束李四显然不妥。最高人民法院《关

〔13〕根据文章内容,此处应指执行力主观范围的扩张。

〔14〕同注〔6〕,第899、902页。

〔15〕马俊驹、余延满:《民法原论》(第3版),法律出版社2007年版,第585页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第10条规定:"监护人的监护职责包括:……管理和保护被监护人的财产……。"被执行人李四的财产由其监护人张六管理,法院的执行行为应该约束张六,限令张六以李四的财产履行赔偿王五10万元的义务,张六拒不履行的,依法予以制裁。《执行规定》第100条规定:"被执行人或其他人有下列拒不履行生效法律文书或者妨害执行行为之一的,人民法院可以依照《民事诉讼法》第102条的规定处理。"部分履行责任人本身属于"被执行人"的范畴,另有部分履行责任人被归入"其他人"的范畴。《民事诉讼法》和最高法院司法解释没有规定执行程序中的履行责任人,履行责任人拒不承担履行责任的依照前述规定处理。

一般而言,被执行人是自然人的,履行责任人是其本人,被执行人是单位的,履行责任人是单位的法定代表人、主要负责人或者直接责任人。履行责任人只能是具有完全民事行为能力的自然人,根据执行依据和现行法律、司法解释以及案件的具体情况确定。包括被执行人是具有完全民事行为能力的自然人的,是其本人;被执行人是无民事行为能力、限制行为能力人的,是其监护人;[16]被执行人是失踪人的,是其财产代管人;[17]被执行人是单位的,是该单位的负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人,设置总会计师的单位还包括总会计师;[18]被执行人是私营个体工商户或合伙经营组织的,是其业主、合伙人[19];执行法院还可以根据案件的具体情况确定。如被执行人甲公司的法定代表人是张三,但张三并没有实际负责甲公司的具体事务,公司实际由李四负责,执行法院据此可以确定李四与张三同为案件的履行责任人。案件的履行责任人为谁应该在执行通知书中予以明确,当履行责任人不履行义务时,依法予以制裁。

四、立法完善

(一)建议法律对被执行主体扩张的情形作出统一规定

对被执行主体扩张的情形,有的是《民事诉讼法》作了原则性规定,如《民事诉讼法》第209条规定的被执行人变更、追加和第208条规定的执行担保;有是散见于《民事诉讼法》之外的其他法律规定,如履行责任人的规定;有的是只有最高人民法院司法解释的规定,如对第三人到期债权的执行。

笔者认为,被执行主体扩张是执行力主观范围的扩张,涉及被扩张主体的实体权利,当被扩张主体拒不履行法律文书确定的义务时,执行法院可依法予以罚款、拘留直至追究刑事责任。[20]根据《立法法》第8条"下列事项只能制定法律:……(四)犯罪和刑罚;(五)……限制人身自由的强制措施和处罚"的规定,因被执行主体扩张涉及被扩张主体犯罪和刑罚以及限制人身自由的强制措施的事项,必须而且只能通过法律来规定。为此,法律要对被执行主体扩张及其情形作出统一规定。一是法律要对被执行主体扩张的各种情形作出规定,将有关司法解释的规定上升为法律。如对第三人到期债权的执行上升为法律。二是法律要增加规定被执行主体扩张的新情形。如执行程序中,公司股东滥用公司法人格逃避债务的现象比较普遍,《公司法》已规定公司法人格否认制度[21],对此法律可规定为被执行人变更、追加的情形。

(二)建议法律规定代位申请执行制度

代位申请执行是指在被执行人与第三人之间的债权债务关系经过法院判决或其他法律文书确认,而被执行人自己不申请执行该法律文书的情况下,申请执行人代被执行人之位,直接向有关法院申请执行该法律文书的

〔16〕依据最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第10条"监护人的监护职责包括:……管理和保护被监护人的财产……"的规定确定。

〔17〕依据最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第30条"人民法院指定失踪人的财产代管人"的规定确定。

〔18〕依据《会计法》第21条"财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章;设置总会计师的单位,还须由总会计师签名并盖章"的规定确定。

〔19〕依据《合伙企业法》第2条"普通合伙企业由普通合伙人组成,合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任"的规定确定。

〔20〕《民事诉讼法》第102条第(六)项规定:"诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情况轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(六)拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。"

〔21〕《公司法》第20条第3款规定:"公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。"

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制度。对被执行人到期债权的执行,根据《执行规定》第63条的规定,第三人提出异议后,即不能对第三人进行执行。只有当第三人无异议而又不履行的,法院才可以裁定对第三人强制执行。有学者认为,如果被执行人对第三人的债权已经经其他判决等法律文书确认了,第三人就没有权利再提出异议,即使提出异议的,法院也可以不理会其异议,而直接强制执行。[22]关于第三人提出异议后不审查的问题,在被执行人对第三人的债权债务关系已经被其他生效法律文书确认的情况下,就不应当允许第三人再提出异议了。提出异议也不用理睬。但这并不是执行法院的审查,而是因为其异议已经被其他的法院审查过了。[23]笔者认为,上述观点虽有利于执行工作,但缺乏法律或司法解释依据。

《合同法》第73条和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第11条已确立了代位权诉讼。债权人代位求偿的民事实体权利自然要靠诉讼法上的代位诉讼来保障。代位诉讼的范围也理应包括代位申请执行。在被执行人自己没有起诉第三人的情况下,债权人尚且可以直接代位提起诉讼,并进而执行,那么在被执行人已经自行起诉并胜诉的情况下,债权人反而不能代位去向法院主张权利,况且,执行到期债权或者代位求偿本身就是在债务人怠于行使自己的权利,不向第三人追索的情况下才存在的制度。在债务人的债权没有经过判决确认的情况下,债权人按照到期债权的普通模式(即到期债权本身未经生效法律文书确认),要求执行到期债权的,多数可能是因为债务人不向第三人主张权利的情况下产生的。那么现在同样是债务人自己不主张权利,不能反而因为到期债权有了执行依据而不允许债权人去执行。因此,代位申请执行完全是有法理依据的,法律应当从维护司法权威、提高执行效率、解决执行难的角度规定代位申请执行制度。

(三)建议法律对未到期债权的执行方法作出规定

现行司法解释规定了对已经到期的债权的执行,这种债权是现实的债权,不是将来不确定的债权,不能附有条件或期限。那么对未到期的债权如何执行呢?对未到期的债权自然不能立即通知第三人履行,但对目前虽未到期,而即将到期的债权,执行法院可以发出附期限的履行通知,由第三人在期限届至时向债权人履行,而且也可以采取履行通知以外的方式执行,如债权转让,也可以采取先冻结债权的做法,禁止第三人在到期后向被执行人支付,待到期后,再发出履行通知书要求第三人直接向申请执行人履行。在此要把履行通知的两项内容分开,区分为债权的冻结和债权的变价。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第105条规定了对到期债权的保全程序。在执行中同样可以参照这个规定采取相应的措施。《执行规定》第51条也规定了对预期收益的执行措施,可以先禁止提取、支付和转让,到期后再向申请执行人支付。

虽然司法解释对未到期债权的禁止支付和冻结的执行方法作出了具体规定,但终究是效力低于法律。对未到期债权的禁止支付和冻结的执行方法涉及第三人的实体权利,必须而且只能通过法律来规定。

(四)建议建立异议人虚假陈述的制裁制度

现行司法解释赋予了第三人的绝对异议权,法院对第三人的异议无论是否真实都无权审查,导致实践中第三人因自身原因或与被执行人串通以逃避执行等原因而滥用异议权,大量的对第三人到期债权的案件无法执行。囿于现行规定,申请执行人只能行使代位诉讼,这既降低了执行效率,又损害了司法权威。协助执行是第三人应有的义务,异议人虚假陈述的行为应属于妨害执行。根据审判与执行的功能分工,审判是确认债权,执行是实现债权,因此执行法院对第三人的异议只能形式审查。但对于第三人提出的异议,申请执行人行使代位诉讼后,经审判程序确认第三人的异议属于虚假陈述的,可依《民事诉讼法》第102条的规定,认定第三人行为属于拒不履行人民法院的判决、裁定。因此,应建立异议人虚假陈述的制裁制度,追究虚假陈述的第三人妨害执行的法律责任,依法给予罚款、拘留直至追究刑事责任。

(作者单位:华东政法大学)

〔22〕黄金龙:《关于人民法院执行工作若干问题的规定实用解析》,中国法制出版社2000年版,第209页。

〔23〕同上注,第205页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net